

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL
PROFESSORA SOLANGE DE OLIVEIRA RAMOS¹

Comentários à Lei de Drogas

Material didático

¹ Mestre em Direito. Professora de Direito Penal do Curso de Direito das Faculdades Integradas HELIO ALONSO – FACHA.
Professorade Direito Penal, Direito Processual Penal e Direitos Humanos em cursos Preparatórios, cursos de Graduação e Pós – graduação em Direito..

COMENTÁRIOS À LEI DE DROGAS (LEI 11.343/2006)

1. ESTRUTURA DA LEI DE DROGAS

A LEI 11.343/2006 apresenta estrutura indicativa dos objetivos pretendidos pelo legislador infraconstitucional, eis que dispõe sobre medidas de prevenção, atenção e reinserção social dos usuários e dependentes, bem como a repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, para tanto destacando a seguinte organização textual:

Título I: disposições preliminares.

Título II: sistema nacional de políticas públicas sobre drogas.

Título III: atividades de prevenção ao uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas.

Título IV: repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas.

Título V: cooperação internacional.

Título VI: disposições finais e transitórias.

2. DA MUDANÇA TERMINOLÓGICA

A expressão *substancia entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica*, utilizada na dicção da lei revogada, foi substituída textualmente pela expressão **droga**, conceituada como substancia ou produto capaz de causar dependência, assim especificada em lei ou em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União ²

Assevere-se que, a nova lei, adota um conceito legal de droga não restrito à categoria de entorpecentes ou de substâncias causadoras de dependência física ou psíquica, ampliando para todas as substâncias ou produtos com potencial de causar dependência, porém condicionadas à inserção em dispositivo legal competente, publicadas periodicamente pelo Ministério da Saúde ³.

3. DOS CRIMES E DAS PENAS

3.1- Posse para consumo pessoal:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

² Parágrafo único do art.1º. da Lei 11.343/2006

³ Art.14, I, a, do Decreto n. 5912/2006

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

O afastamento da aplicação de pena privativa de liberdade, prevendo ao usuário de drogas, penas restritivas de direitos e advertência, fez nascer no campo doutrinário, a idéia de descriminalização da posse de droga para consumo próprio. À evidência, o artigo em comento não implica em hipótese de *abolitio criminis* do delito de posse de droga para consumo pessoal, tendo ocorrido, tecnicamente, uma despenalização, eis que excluiu a pena privativa de liberdade como pena principal. É de se aduzir, ainda, que a conduta relativa ao usuário foi colocada em capítulo intitulado “dos crimes e das penas”, não sendo crível a premissa de equívoco do legislador.

A conduta prevista no art.28 da Lei 11.343/06 é de competência dos Juizados Especiais Criminais, incumbindo ao Ministério Público, quando do oferecimento da proposta de transação penal, indicar a pena ou penas que deverão ser impostas ao usuário. Diferentemente do que ocorria na disciplina anterior, sob a dicção da lei 6368/76, na ocorrência de descumprimento da transação, o ministério público não oferecerá denúncia pelo porte, podendo, o juiz, realizar nova censura verbal ou aplicar o pagamento de uma multa. É possível, também, que o usuário obtenha nova proposta de transação penal, ainda que já beneficiado há menos de 05(cinco) anos.

A conduta do usuário vem representada por cinco núcleos, a saber: adquirir, guardar, ter em depósito, transportar e trazer consigo. Trata-se de crime de ação múltipla, afastando o instituto do concurso de crimes, caso o agente incorra em mais de uma das condutas descritas, porque traduzido como delito único.

A aplicação das penas previstas nos incisos I, II e III do art.28 da Lei 11.343/06 alcança os processos em curso, bem como os findos, com trânsito em julgado⁴, em homenagem ao princípio da retroatividade de lei mais benéfica.

São modalidades de sanção não privativa de liberdade previstas no art.28 da Lei 11.343/06:

- I- *Advertência sobre os efeitos da droga*: modelo sem precedentes na legislação penal que apresenta natureza jurídica de pena, devendo ser aplicada na própria audiência preliminar, em conformidade com o rito procedimental da Lei 9099/95, gerando reincidência.
- II- *Prestação de serviços à comunidade*: na dicção da nova lei, abandona o caráter substitutivo à pena privativa, assumindo a natureza de pena principal
- III- *Comparecimento a programa ou curso educativo*: tem caráter inovador, nos moldes da primeira punição e, da mesma forma, com natureza jurídica de pena, gerando reincidência.

⁴ Súmula 611 STF - TRANSITADA EM JULGADO A SENTENÇA CONDENATÓRIA, COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES A APLICAÇÃO DE LEI MAIS BENIGNA.

Outra modalidade prevista na *novel* legislação, aplicável ao agente que injustificadamente se recuse a cumprir as sanções previstas nos incisos II e III, é a *admoestação verbal*, consistente em censura verbal realizada pelo magistrado sobre a exigibilidade de cumprimento das medidas impostas.

Ainda considerando os núcleos descritos no art.28 da Lei 11.343/06, mister frisar a incriminação de vários agentes que, em conjunto, adquiram a droga para consumo. Neste caso, absolutamente viável a imputação de todos os agentes, mesmo que somente um deles tenha sido surpreendido com a droga, porquanto o acordo de vontades e o vínculo psicológico unem os infratores objetivando um propósito comum.

“Havendo acordo de vontades, um vínculo psicológico e um propósito comum a unir os infratores, o porte da droga para uso próprio incrimina todos os participantes presentes, pouco importando se cada um deles traz consigo uma parte da droga ou se toda ela se encontra nas mãos de apenas um deles.”⁵

A análise da quantidade de droga encontrada em poder do réu segue a seguinte orientação legislativa

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Assim, a tipicidade da conduta não fica prejudicada, em razão da mínima quantidade apreendida, em conformidade com jurisprudência integrante de coletânea com base na lei 6368/76:

“A quantidade ínfima da droga não desnatura o ilícito. o crime de uso de entorpecente é contra a saúde publica e a porção mínima utilizada pelo agente é irrelevante para a configuração do delito.”⁶

Em sentido contrário, alguns julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo, entendendo que a ínfima quantidade torna a conduta atípica:

“A apreensão de ínfima quantidade de maconha, encontrada em “fininho”, parcialmente queimado, não configura o delito do art.16 da Lei 6368/76”

Considerando o tratamento dispensado pela lei 11.343/06, às condutas descritas no art.28, bem como as modalidades de sanções com natureza de pena, incluindo a advertência ao usuário, perde o objeto a discussão acerca da ínfima quantidade como medida caracterizadora ou não do delito, sendo limite para a afirmação do consumo pessoal.

⁵ TJMG – JM, 134/329

⁶ STJ – JSTJ 68/384

A plantação destinada à preparação de substância ou produto capaz de produzir dependência física ou psíquica, desde que a semeadura, cultivo ou colheita caracterize consumo pessoal, da mesma forma, incide nas medidas cominadas para as condutas definidas no *caput* do art.28 da lei 11.343/06.

As condutas relativas à plantação apresentam tratamento diferenciado em confronto com a Lei 6368/76, isto porque, nesta, consideradas como tráfico de entorpecentes. A admissão da *posse para uso pessoal*, relevando a natureza, a quantidade, o local e as condições da substância apreendida, se desenvolvia em sede jurisprudencial.

O parágrafo 2º. da lei 11.343/06 revela os critérios objetivos e subjetivos que serão avaliados pelo julgador, para a definição de consumo pessoal, a seguir apresentado:

§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Quanto à dosimetria das penas, por disposição legal, será aplicada no limite máximo de 05 meses, admitido o prazo de 10 meses no caso de reincidência. As penas possuem *status* de pena principal, porém, não privativas de liberdade, logo, o instituto da prescrição está necessariamente regrado e definido em 02 anos, conforme art.30:

“Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.”

Prevê a nova lei, a aplicação ao usuário de drogas do procedimento previsto na Lei n. 9.099/95, com o imediato encaminhamento do agente ao Juizado Especial Criminal, ou, na impossibilidade, com a assinatura de compromisso de a ele comparecer, lavrando-se Termo Circunstanciado pela autoridade policial, que deverá providenciar as requisições dos exames e perícias necessários.

A possibilidade de adequação ao procedimento relativo aos crimes de menor potencial ofensivo, está consagrada textualmente, como se observa no § 1º do art. 48 que segue:

"O agente de qualquer das condutas previstas no art. 28 desta Lei, salvo se houver concurso com os crimes previstos nos arts. 33 a 37 desta Lei, será processado e julgado na forma dos arts. 60 e seguintes da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Criminais"

O não cabimento da prisão em flagrante disposto na dicção da Lei 9099/95, da mesma forma, eis que a condição de usuário apresenta caráter de crime de menor potencial ofensivo, também não tem aplicação na Lei 11.343/06, conforme §2º.do art.28, cujo conteúdo aponta para a vedação expressa à

prisão em flagrante do agente surpreendido na posse de drogas para consumo pessoal.

É de se frisar que o autor do fato não poderá ser preso em flagrante, afastando, entretanto, apenas a não-lavratura do auto de prisão em flagrante e a não-condução ao encarceramento, porém, não há impedimento à captura do autor do fato e conseqüente apresentação perante a autoridade competente.

Na lição e comentários de Andreucci⁷, sobre a prestação jurisdicional na hipótese, o autor observa:

“O juiz, porém, ao sentenciar, não poderá, por óbvio, atribuir como pena a advertência, pois essa, devido à sua condição de sanção penal sui generis, somente pode ser objeto de transação. Resta, pois, para o juiz apenas a prestação de serviço à comunidade e a participação em curso ou programa educativo.”

3.2- Tráfico de drogas

O tipo penal do art.33 da Lei 11.343/06, apresenta dezoito verbos (importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, fornecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar e entregar), modalidade de tipo misto alternativo, hipótese em que, a prática de mais de uma conduta, não implica concurso de crimes, mas um único delito.

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena — reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

I — importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II — semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

⁷ ANDREUCCI, Ricardo Antonio. Legislação Penal Especial.. SP: Saraiva, 2009

III — utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

§ 2º Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga:

Pena — detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa de 100 (cem) a 300 (trezentos) dias-multa.

§ 3º Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem:

Pena — detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28.

§ 4a Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Em sede de nova lei de drogas, mantendo-se o que já ocorria na vigência da lei 6368/76, é hipótese de **Norma penal em branco**, implicando em aplicação de norma complementadora, *in casu*, heterogênea, cuja dicção defina as drogas desautorizadas ou em desacordo com determinação legal, assim especificadas relacionadas em listas atualizadas pelo Poder Executivo da União. Cabe ao Ministério da Saúde, por consequência, publicar periodicamente listas atualizadas sobre as substâncias e produtos considerados drogas.

O **elemento normativo** se depreende da expressão "sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".e, o **Elemento subjetivo** é o dolo.

O **momento consumativo** ocorre com a prática de qualquer das ações constantes da figura típica, independentemente de qualquer outro resultado. Importante notar que, dentre os dezoito núcleos integrantes do art.33, há aqueles que constituem crimes instantâneos (adquirir, fornecer, vender etc.) e outras que constituem crimes permanentes (ter em depósito, guardar, expor à venda etc.). A importância da identificação da referida classificação remete ao tema **tentativa**, porque admitida nos crimes instantâneos, não nos permanentes.

Existe entendimento no sentido da inadmissibilidade da tentativa no crime de tráfico, em razão da multiplicidade de condutas incriminadas (RT, 777/724 e 613/288).

Nesse sentido⁸:

"A jurisprudência e a doutrina predominantes não admitem a tentativa de tráfico de entorpecente. Evidenciado o começo de execução já se tem o crime por consumado. Isto porque o delito em questão constitui-se de ações múltiplas, bastando, para sua configuração, que a conduta do agente seja subsumida numa das ações expressas pelos verbos empregados no art. 12 da Lei n. 6.368/76, o que afasta a tentativa. Ademais, neste tipo de crime, o bem jurídico tutelado é a saúde pública, cujo objetivo da lei é evitar o dano para a saúde, que o uso das drogas causa, sendo prescindível a ocorrência efetiva do dano, para a configuração do delito, o que afasta a admissibilidade do 'conatus'

O § 1º do artigo 33 coleciona as várias figuras equiparadas ao crime de tráfico, cujas condutas, desde que praticadas "sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar", ensejaram a cominação da mesma punição. As figuras previstas no inciso I, indicativas de tipo misto alternativo, têm como objeto material "matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas".

Conforme preleciona o doutrinador Vicente Greco Filho⁹:

"'matéria-prima' é a substância de que podem ser extraídos ou produzidos os entorpecentes ou drogas que causem dependência física ou psíquica. Não há necessidade de que as matérias-primas tenham já de per si os efeitos farmacológicos dos tóxicos a serem produzidos: basta que tenham as condições e qualidades químicas necessárias para, mediante transformação, adição etc., resultarem em entorpecentes ou drogas análogas".

Na nova lei, conforme descreve o art. 28, § 1º., o legislador equipara à posse para consumo pessoal, à sementeira, cultivo ou colheita de plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. Caso a sementeira, o cultivo e a colheita não sejam para consumo pessoal, estará caracterizada a figura do tráfico de drogas.

A análise da nova lei de drogas, no que concerne às condutas induzir, instigar e auxiliar, em comparação ao tratamento dado pela revogada, na lição de Andreucci :

"Pela redação do antigo art. 12 ('induzir, instigar ou auxiliar a usar'), o tipo exigia, para sua consumação, o efetivo uso da droga pelo sujeito passivo. Já no novo dispositivo, o verbo "usar" foi substituído pela expressão "ao uso", de forma que o delito se consuma com o simples auxílio moral ou

⁸ TJSC — JC, 61/279

⁹ Tóxicos: prevenção — repressão: comentários à Lei n. 6.368, de 21-10-1976, 5. ed., São Paulo: Saraiva, 1987, p. 97

material, independentemente do uso da droga pela vítima. A consumação é antecipada à simples conduta do agente, dispensando um resultado naturalístico. Induzir significa criar um propósito inexistente. Instigar significa reforçar propósito já existente. Auxiliar e fornecer meios materiais, no caso, para o consumo de drogas."

O inciso III do art.33 pune a conduta daquele que utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, para o tráfico ilícito de drogas.

Ressalta, com propriedade, Vicente Greco Filho (*Tóxicos, cit.*, p. 100-1) que,

"se alguém recebe as chaves de um imóvel para um fim de semana e aproveita a oportunidade para entregá-las a terceiro, para que dele se utilize para o uso ilegal de entorpecentes, estará incidindo em incriminação legal".

Na jurisprudência, sob a vigência da lei anterior:

"Provado que o magistrado facilitou a terceiros que guardassem cocaína no interior de seu apartamento e provada, também, a materialidade do crime, impõe-se sua condenação pelo tipo do art. 12, § 2º, II, da Lei de Entorpecentes, com a perda do cargo público"¹⁰

O art. 12, § 2º, III, da lei 6368/76, trazia como conduta equiparada ao tráfico, ainda, a contribuição de qualquer forma para incentivar ou difundir o uso indevido ou o tráfico ilícito de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica.

A nova lei aboliu essa figura típica. Em seu lugar, ainda que em circunstâncias diferentes, o legislador descreveu as figuras típicas do financiamento ou custeio do tráfico, conforme art. 36 e a colaboração, como informante, com grupo, organização ou associação destinadas à prática do tráfico, tipificada no art. 37.

O art. 33, § 3º, cuida de uma figura típica nova, sem correspondente na Lei na lei anterior – o tráfico privilegiado:

" Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem;

Para a caracterização do crime de tráfico privilegiado, entretanto, são exigidos dois elementos subjetivos do tipo:

- a) elemento subjetivo positivo: "para juntos consumirem".
- b) elemento subjetivo negativo: "sem objetivo de lucro", logo, a intenção do agente é o consumo de drogas e não sua mercancia.

O oferecimento deve dar-se "eventualmente", posto que a habitualidade caracteriza crime de tráfico. A conduta típica "oferecer" indica que o crime é formal, consumando-se independentemente da ocorrência do resultado naturalístico, que seria a aceitação e consumo conjunto da droga.

Se o agente, para oferecer a droga a pessoa de seu relacionamento, sem objetivo de lucro e para juntos a consumirem, antes a tiver trazido consigo, para consumo pessoal, estaremos diante de concurso material de crimes, aplicando-se a pena cumulativamente.

Trata-se de crime de menor potencial ofensivo, sujeita, portanto, ao procedimento da Lei n. 9.099/95.

Sobre a causa de diminuição de pena, inserta no parágrafo 4º. do art.33 da nova lei, preleciona Andreucci:

“Para que o agente obtenha a redução de pena, deve satisfazer os seguintes requisitos:

- a) ser primário;
- b) possuir bons antecedentes;
- c) não se dedicar às atividades criminosas;
- d) não integrar organização criminosa.”

É de se observar que as cláusulas negativas destacadas nas letras c e d objetivam o favorecimento do agente. Ao Ministério Público caberá a prova das referidas cláusulas, visto que, sem essa prova, a aplicação da diminuição será inafastável, porque satisfeitos os demais requisitos legais.

Trata-se de inafastável *novatio legis in melius*, de aplicação imediata aos processos em andamento e, ainda, de retroatividade obrigatória.

Como bem ensina o referido doutrinador:

“Ressalte-se, entretanto, que a causa de diminuição não poderá incidir, nos processos em curso ou já julgados, sobre a pena de 3 a **15** anos fixada pelo art. 12 da Lei n. 6.368/76, mas sim sobre o novo montante de 5 a 15 **anos**. Assim, se o agente, no processo em curso, **foi** denunciado pela prática do art. 12 da Lei n. 6.368/76, não pode pretender a aplicação **da** causa de diminuição sobre a pena mínima de 3 anos. se satisfeitos **os** requisitos do § 4º do **art.** 33. Nesse caso, se o juiz aplicar a nova causa de diminuição, deverá calculá-la tendo como base a pena mínima de 5 anos.”

Para os processos **findos**, com trânsito em julgado, a análise das cláusulas negativas acima mencionadas, dificilmente poderá ser feita pelo juiz da execução (Súmula 611 do STF), já que demanda dilação probatória. A solução será requerer a aplicação da lei nova mais benéfica (redução de pena) através

de revisão criminal. Nesse caso, o ónus da prova é de quem requer a aplicação da lei nova mais benéfica.

Sobre a quantidade de droga e a caracterização de tráfico, eis o posicionamento dos tribunais:

"A grande quantidade de drogas apreendida pode e deve ser utilizada na dosimetria" (STJ — HC 11.235 — Rei. Min. José Arnaldo da Fonseca—j. 16-3-2000).

"Em tema de comércio clandestino de entorpecentes, o tráfico não pode ser presumido tão-só com arrimo na quantidade da substância apreendida, pois uma pequena quantidade pode ser saldo de uma grande, enquanto que uma razoável quantidade, para uso próprio, não admite a presunção do desígnio mercantilista, que exige pelo menos uma razoável evidência de habitualidade" (TACrim — JTACrim, 51/203).

"Para se identificar o traficante e distingui-lo do usuário, não é só o problema da quantidade que se deve levar em conta. Os próprios traficantes raramente são encontrados com grande quantidade de tóxico, pois se de um lado não pretendem correr o risco de perder tudo numa investida policial, de outro, a pequena quantidade pode prestar-se a vendas a varejo e mesmo à dissimulação do característico de mercancia" (TACrim — JTACrim, 49/330).

Tema relevante, em crime de tráfico ilícito de drogas, é a alegação de **flagrante preparado**, com o propósito de obter o reconhecimento de crime impossível. A hipótese é aquela em que policiais, fazendo-se passar por usuários, buscam adquirir drogas de traficante, prendendo-o em flagrante delito no ato da venda.

Considera-se **flagrante preparado** quando o provocador interfere de forma a induzir o agente à prática do crime. Figura totalmente diferente é a do **flagrante esperado**, quando a polícia, alertada da prática delituosa, surpreende o delinquente no ato da infração, lavrando então a prisão, não tendo a iniciativa do crime partido dos agentes de autoridade. Esta é a orientação do STF, súmula 145: "Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação" e jurisprudência "No flagrante preparado há provocação ou induzimento de parte da autoridade, para que alguém pratique fato definido como crime, de modo a provocar o flagrante " (STF — RTJ, 120/164).

A nova Lei de Drogas prevê expressamente, no art. 44, a proibição da conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos, nos casos dos crimes dos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37.

Entretanto, com a recente alteração da Lei dos Crimes Hediondos, introduzida pela Lei n. 11.464, de 28 de março de 2007, os crimes hediondos e assemelhados, dentre eles o de tráfico, passaram a comportar a concessão de

liberdade provisória sem fiança (art. 2^a, II). sendo alterado, por consequência, o teor do art. 44 da Lei de Drogas. Essa permissão de concessão de liberdade provisória, apontada na alteração legislativa, alcança os arts. 33 e 34 a 37 da Lei de drogas?

Segundo orientação da doutrina especializada:

“A melhor solução é considerar suscetíveis de liberdade provisória também os crimes dos arts. 34 a 37 da Lei de Drogas, não obstante serem figuras típicas diferentes do tráfico, não mencionadas expressamente pela Lei dos Crimes Hediondos, mas que com ele guardam íntima relação. Portanto, aos crimes de tráfico de drogas, aparelhagem para a produção de drogas, associação para o tráfico, financiamento ou custeio do tráfico e colaboração para o tráfico, não cabem: a) fiança; b) sursis; c) graça; d) indulto; e) anistia; f) conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.”

Quanto ao instituto do livramento condicional, a nova lei, ao referir-se à reincidência específica, restringiu-a aos casos dos crimes dos arts. 33, *caput* e § 1º, e 34 a 37. Portanto, não pode ser vedado o livramento condicional se o condenado for reincidente em outro crime hediondo ou assemelhado, como ocorria sob a vigência da lei anterior, em atenção ao disposto no art. 5º da Lei n. 8.072/90. A pena pelo crime de tráfico de drogas será cumprida inicialmente em regime fechado, sendo admitida a progressão após o cumprimento de dois quintos da pena, se o criminoso for primário, ou três quintos se for reincidente (art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei n. 8.072/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/2007).

3.3 - Aparelhagem para a produção de substância entorpecente

O artigo em comento vem representado por onze verbos (fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar, possuir, guardar e fornecer), traduzindo tipo misto alternativo, em que a prática de mais de uma conduta não implica concurso de crimes, mas um único delito.

Art. 34. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinado, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena — reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) a 2.000 (dois mil) dias-multa.

Nas palavras de Vicente Greco Filho¹¹, o objeto do tipo é o maquinário, aparelho, instrumento ou objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas:

"para a caracterização do delito, portanto, a fim de que não se incrimine injustamente se houver destinação inocente, há necessidade de que, no caso concreto, fique demonstrado que determinados aparelhos, maquinismos, instrumentos ou objetos estejam *efetivamente* destinados à preparação, produção ou transformação de substância proibida".

O elemento subjetivo é o dolo, apresentando como momento consumativo a prática das condutas descritas como núcleos do tipo incriminador. A modalidade tentada é admitida nas condutas "fabricar", "adquirir", "vender", "fornecer", "transportar" e "distribuir".

3.4 - Associação para o tráfico

A conduta vem representada pelo verbo "associar(-se)", que significa agregar-se, unir-se. O tipo penal exige que *duas ou mais* pessoas se associem para o fim de, reiteradamente *ou não*, praticar os delitos dos arts. 33, *caput* e § 1^a, e 34.

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, *caput* e § 1^a, e 34 desta Lei:

Pena — reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas do *caput* deste artigo incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei.

A este ponto, algumas distinções são necessárias:

1) O parágrafo único do art. 35 prevê a figura da associação para a prática reiterada do crime de financiamento ou custeio do tráfico. Nesse caso específico, o dispositivo legal condiciona a tipificação à "prática reiterada" do crime definido no art. 36, excluindo, portanto, do abrigo legal a associação eventual para a prática de tal crime.

2) O Crime de associação para o tráfico se distingue do crime de bando ou quadrilha (art. 288 do CP), porque neste há a necessidade de associarem-se mais de 3 pessoas, logo, no mínimo 4, para a prática de crimes. Já na associação para o tráfico, exige-se um número mínimo de 2 associados,

¹¹ *Tóxicos: prevenção — repressão; comentários à Lei n. 6.368, de 21-10-1976*, 5. ed.. São Paulo: Saraiva, 1987, p. 103

especificamente para a prática dos crimes dos arts. 33, 'caput' e § 1^a, e 34 da Lei de Drogas.

3) Não há qualquer impedimento ao reconhecimento do concurso material entre os arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, eis que os referidos crimes apresentam pressupostos distintos e são autônomos.

3.5 – Financiamento e custeio do tráfico

O art.36 descreve uma nova figura típica que não existia na lei anterior, onde o financiador era enquadrado na conduta do art. 12. § 2^a, III, da Lei n. 6.368/76.

Art. 36. Financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1^o, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 20 (vinte) anos, e pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) a 4.000 (quatro mil) dias-multa.

O tipo descrito no art.36 apresenta como núcleos os verbos "financiar", que significa prover às despesas de alguma atividade, e "custear", que significa correr com as despesas de algo, entretanto, estas condutas devem ser da prática dos delitos dos art. 33, *caput* e § 1^o, e art. 34. A figura do financiador não pode participar do tráfico de drogas, porque, caracterizada esta conduta, estará configurado um único crime – o tráfico, aplicando – se a causa de aumento de pena disposta no art.40, VII da lei sob análise.

O crime de financiamento e custeio se consuma com a realização efetiva das referidas atividade e, a tentativa, é admitida.

3.6 – Colaboração com o tráfico

O art.37 da Lei 11.343/06 trata da colaboração para o tráfico, em que o agente atua como informante junto ao grupo, organização ou associação:

Art. 37. Colaborar, como informante, com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1^o, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e pagamento de 300 (trezentos) a 700 (setecentos) dias-multa.

Como lecionam os doutrinadores pátrios

“Existem diversas espécies de colaboração com grupos, organizações ou associações criminosas. Em matéria de crime organizado, podemos destacar como espécies de colaboração: a informação ou vigilância de pessoas, bens ou instalações; a construção, acondicionamento, cessão ou utilização de alojamentos ou depósitos; a ocultação ou traslado de pessoas vinculadas às organizações criminosas armadas, ou terroristas; o treinamento ou assistência ao treinamento de membros das organizações criminosas etc. Em todas as

hipóteses, a colaboração deve vincular-se às atividades ou finalidades dos grupos, associações ou organizações criminosas.

Com base no conteúdo especificado sobre as formas de colaboração, necessária a formalização da definição de informante:

“Informante: é aquele que presta as informações ao grupo, associação ou organização criminosa voltada à prática do tráfico. Pode o agente, por exemplo, fornecer informações sobre diligências policiais de que tem conhecimento, sobre a existência ou identidade de agentes infiltrados, sobre outras providências visando a persecução ao tráfico, tais como quebra de sigilo bancário, interceptações telefônicas, escutas ambientais etc. Se o informante for funcionário público, estará incurso na causa de aumento de pena do art. 40, II, da nova lei.”

Vale lembrar que a colaboração com o traficante individual será considerada conduta atípica. Entretanto, se a colaboração puder ser caracterizada como ato de participação no crime de tráfico, o informante será considerado co-autor ou participe dos crimes dos arts. 33, *caput* e § 1^a, e 34 da nova lei.

A conduta será consumada com a efetiva colaboração como informante, independente da prática de qualquer ato pelo grupo, associação ou organização criminosa e, a configuração do crime dispensa a reiteração, bastando uma única informação para tipificação do crime.

3.7 - Prescrição culposa da droga

Na classificação doutrinária dos crimes, se caracteriza como crime próprio, isto porque, somente podem ser sujeitos ativos o médico, o dentista, o farmacêutico ou o profissional de enfermagem. O tipo não descreve sobre estes agentes, entretanto, à evidência, apenas médico, dentista, farmacêutico ou profissional de enfermagem continua sendo os sujeitos ativos do crime, uma vez que somente essas pessoas possuem atribuição para prescrever ou ministrar drogas.

Art. 38. Prescrever ou ministrar, culposamente, drogas, sem que delas necessite o paciente, ou fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e pagamento de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) dias-multa.

Parágrafo único. O juiz comunicará a condenação ao Conselho Federal da categoria profissional a que pertença o agente

A conduta está representada pelos núcleos prescrever e ministrar, *sem que dela necessite o paciente, ou em doses excessivas ou ainda em desacordo com determinação legal ou regulamentar.*

A conduta típica passou a abranger qualquer prescrição culposa, seja ela em paciente que necessita da droga, mas em doses menores, ou o paciente que dela não precisa, mas é atingido pela conduta culposa do agente.

O elemento subjetivo é a culpa — negligência, imprudência ou imperícia. Caso o agente atue dolosamente, estará caracterizado o crime do art. 33, *caput*, da Lei de Drogas. A consumação se dá com a realização das condutas tipificadas e em relação à tentativa, não tem sido admitida, entretanto, é exemplar a hipótese apresentada por Greco Filho sobre a tentativa, quando ressalva que “no envio de receita pelo correio, que vem a ser interceptada pelas autoridades, seria possível caracterizar como tentativa”.

O parágrafo único do art.39 prevê o efeito da condenação, considerando as categorias profissionais envolvidas no tipo em estudo.

3.8 – Causas de aumento de pena:

O art.40 da Lei 11.343/06 enumera sete circunstâncias que aumentam a pena , abordando (1) o tráfico transnacional, exigindo, agora, apenas a entrada ou saída da droga do território nacional, (2) o agente que se prevalece da função pública para se lançar ao comercio clandestino de drogas, alcançando também àquelas pessoas que não são titulares de função pública, porém, possuem a missão de educação, guarda, vigilância e proteção, (3) atuação do tráfico em locais de grande circulação de pessoas,(4) com emprego de violência, grave ameaça, arma de fogo ou processo de intimidação difusa ou coletiva, (5) quando caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal, (6) envolvendo pessoas sem plena capacidade de entendimento, de discernimento ou de autodeterminação, seja pela idade, seja por qualquer outra causa, e que, por essa razão, seriam mais facilmente influenciadas e atingidas pela difusão do vício, (7) aplica-se ao traficante que financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos nos arts.33 a 37, além de participar desses crimes; caso seja, apenas, o financiador dos crimes, estará configurado o crime autônomo do art. 36, afastada a causa de aumento.

3.9 – Delação premiada

A redução da pena em razão da delação, prevista no art.41 da Lei 11.343/06, se subordina ao cumprimento dos seguintes requisitos:

- a) colaboração voluntária do indiciado ou acusado;
- b) identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime;
- c) recuperação total ou parcial do produto do crime

É de se ressaltar que o artigo em análise não admite o perdão judicial e, a redução da pena será aplicada quando do decreto condenatório, ficando vedada a redução de pena *em tese*, ou seja, antes da condenação, com o propósito de obter os benefícios referentes aos institutos despenalizadores, tais como os previstos na Lei n. 9.099/95.

3.10 – A inimizabilidade: vício e dependência

O vício se caracteriza pela compulsão no uso da droga, entretanto, sem retirar a consciência da ilicitude, por conseguinte, mantida a capacidade de discernimento. A dependência é, conceitualmente, doença mental, retirando absolutamente a responsabilidade penal do agente.

O art.45 da Lei 11.343/06 define a dependência como a intoxicação crônica por uso repetido de drogas, que determina doença mental supressora da capacidade de entendimento e de determinação no momento do fato criminoso.

Assim, visto que o vício e a dependência são figuras distintas, a aferição quanto à configuração de uma ou outra, é matéria adstrita ao elemento imimizabilidade.

Nos dizeres de Andreucci:

Declarando-se dependente **na** defesa preliminar, o **réu**, após a decisão do juiz ao receber a denúncia, será submetido a exame de dependência toxicológica, que se processará nos moldes do disposto nos arts. 149 a 154 **do** Código de Processo Penal.

4) Procedimento Criminal

No caso do art.28 da Lei 11.343/06, o processo e julgamento seguirá a dicção da Lei 9.099/95, da seguinte forma:

1. Lavratura de Termo Circunstanciado pela autoridade policial.
2. Encaminhamento do autor do fato ao JECRIM, ou lavratura de termo de compromisso de comparecimento
3. Requisição dos exames e perícias necessários
4. Realização da audiência preliminar
5. Aceita a proposta de transação pelo autor do fato e seu defensor, segue-se a homologação pelo juiz e a imposição da pena
6. Não aceita a proposta de transação pelo autor do fato ou seu defensor, o Ministério Público oferecerá denúncia oral, observando-se o rito dos arts. 77 e seguintes da Lei n. 9.099/95.

Quanto ao tráfico, o procedimento pode ser esquematicamente apresentado da seguinte forma:

- 1) Prisão em flagrante, com a condução do agente ao distrito policial e a lavratura do respectivo auto.
- 2) Comunicação da prisão ao juiz competente, em 24 horas
- 3) Elaboração de laudo de constatação para estabelecimento da materialidade do delito, verificando-se a natureza e a quantidade da droga.
- 4) Conclusão do inquérito policial: 30 (trinta) dias estando o indiciado preso e 90 (noventa) dias estando o indiciado solto. Esses prazos podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária.
- 5) Remessa dos autos de inquérito policial ao juízo
- 6) Em juízo, aos autos de inquérito policial será dada vista ao Ministério Público
- 7) Denúncia do Ministério Público no prazo de 10 dias, podendo arrolar até 5 testemunhas e requerer diligências.
- 8) Notificação do acusado para ofertar defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 dias
- 9) Defesa prévia
- 10) Decisão do juiz em 5 dias
- 11) Recebimento da denúncia
- 12) Realização da audiência de instrução e julgamento:
 - a) interrogatório
 - b) inquirição de testemunhas
 - c) debates orais e
 - d) sentença.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

ANDREUCCI, Ricardo Antonio. Legislação penal especial. São Paulo: Saraiva.

JESUS, Damásio E. Lei antitóxicos anotada.. São Paulo: Saraiva.

TEXTO COMPLEMENTAR

NOVA LEI DE DROGAS: RETROATIVIDADE OU IRRETROATIVIDADE? (PRIMEIRA PARTE)

LUIZ FLÁVIO GOMES

Doutor em Direito penal pela Faculdade de Direito da Universidade Complutense de Madri,
Mestre em Direito penal pela USP, Secretário- Geral do IPAN - Instituto Panamericano de
Política Criminal, Consultor e Parecerista, Fundador e Presidente da Rede LFG – Rede de
Ensino Luiz Flávio Gomes (1ª Rede de Ensino Telepresencial do Brasil e da América Latina -
Líder Mundial em Cursos Preparatórios Telepresenciais – www.lfg.com.br)

ROGÉRIO SANCHES CUNHA

Professor da Escola Superior do MP-SP. Professor de Direito penal e Processo penal na Rede
de Ensino Luiz Flávio Gomes – Rede LFG e Promotor de Justiça em São Paulo

Quando há uma efetiva sucessão de leis penais (no tempo do crime vigorava a lei “A” e no tempo do processo, da sentença ou da execução passa a vigorar a lei “B”, regente do mesmo fato) fala-se em conflito de leis penais no tempo (ou sucessão de leis penais). Qual delas deve ter incidência no caso concreto: a lei do tempo do crime (lei “A”) ou a lei do tempo do processo, da sentença ou da execução (lei “B”)?

Para resolver o assunto contamos com dois princípios básicos (irretroatividade da lei penal nova mais severa e retroatividade da lei penal nova mais benéfica) e dois outros correlatos (ultra-atividade da lei penal anterior mais benéfica e não ultra-atividade da lei penal anterior mais severa). Ao conjunto de regras e princípios que regulam o conflito de leis penais no tempo dá-se o nome de *Direito penal intertemporal*.

Esse fenômeno da sucessão de leis penais aconteceu uma vez mais com o advento da Lei 11.343/2006 (nova lei de drogas). Comparando-se essa lei nova com a antiga (Lei 6.368/1976), nota-se que em muitos pontos a lei nova ora é mais favorável, ora é mais severa. Em todos os pontos em que for favorável retroage (deve retroagir para beneficiar os réus). Do contrário, quando maléfica não retroage. São muitas as situações que merecem nossa atenção. Vejamos alguns exemplos:

a) Primeiro:

O art. 33 da Lei nova é irretroativo, pois, repetindo os mesmos núcleos do art. 12, previu consequências penais (corporal e pecuniária) mais gravosas. Atenção apenas para a Súmula 711 do STF, no caso de crime permanente, ou seja, se a conduta permanente (ter consigo, ter em depósito, guardar substância entorpecente etc.) teve início antes da nova lei (até o dia 07.10.06) e continuou sendo praticada após o dia 08.10.06, incide a nova lei, mesmo que mais severa (crime permanente que continua sendo praticado mesmo depois do advento de nova lei, é regido pela nova lei – Súmula 711 do STF).

b) Segundo:

O art. 33, § 1º, I, da Lei nova é irretroativo, pois, repetindo os mesmos núcleos do art. 12, I, previu novo objeto material (insumo) com conseqüências penais (corporal e pecuniária) mais gravosas. Atenção apenas para a Súmula 711 do STF, no caso de crime permanente (cf. acima nossas observações sobre esse ponto).

c) Terceiro:

O art. 33, § 1º, II, da Lei nova é irretroativo, pois, repetindo os mesmos núcleos do art. 12, II, previu conseqüências penais (corporal e pecuniária) mais gravosas. Atenção apenas para a Súmula 711 do STF, no caso de crime permanente. Deve ser lembrado, ainda, que o plantio de pequena quantidade para uso agora está equiparado ao mero porte (art. 28), retroagindo para aqueles que antes subsumiam ao tipo do tráfico. Quem, no entanto, ensinava ser tal comportamento atípico (lacuna), deve aplicar a novel Lei de forma irretroativa.

d) Quarto:

O art. 33, § 1º, III, restringiu a punição para aquele que age visando a prática do *tráfico*. Nesse caso, o tipo novo é irretroativo, vez que a sanção trazida pela Lei 11.343/06 é mais gravosa (atenção apenas para a Súmula 711 do STF, no caso de crime permanente). Se a cessão do local for para *uso*, a novel lei não mais aplica a mesma pena do tráfico, tratando a hipótese como simples induzimento, tipificado no parágrafo seguinte, com pena menos grave (logo, retroativo).

e) Quinto:

A Lei nova, no caso do art.33 §2º., em que o agente induz, instiga ou auxilia alguém a usar entorpecente, deve retroagir porque trouxe sanções penais menos gravosas.

f) Sexto:

O comportamento descrito no art. 33, § 3º, antes da Lei 11.343/06, era, para alguns, tratado como tráfico (fornecer, ainda gratuitamente, art. 12 da Lei 6.368/1976). Agora, com a alteração trazida pela Lei 11.343/06, o fornecedor que age sem finalidade de lucro e de forma eventual, visando, inclusive, a consumir a droga oferecida com pessoa de seu relacionamento (tráfico ocasional e íntimo), tem pena bem menos gravosa, aliás de menor potencial ofensivo (está clara a retroatividade). A retroatividade existe mesmo para aqueles que antes já subsumiam a hipótese ao porte para uso (art. 16, da antiga lei de drogas), vez que a pena máxima deixou de ser de dois passando para um ano. O novo dispositivo, entretanto, é irretroativo no que diz respeito à pena de multa: a nova é muito mais severa que a anterior.

Quem aplica a lei nova favorável? Se o processo está em andamento em primeira instância, a lei nova favorável deve ser aplicada pelo juiz de primeira instância; se está no tribunal, cabe ao tribunal aplicá-la; se existe execução em andamento (provisória ou definitiva) a incidência da nova lei é da competência do juiz das execuções (Súmula 611 do STF).

Situação peculiar: o juiz das execuções tem competência para aplicar a lei nova favorável, fazendo-se os ajustes necessários na pena (conforme a lei nova). De qualquer maneira, pode ser que o caso demande exame valorativo de provas ou mesmo produção de novas provas. Nessa hipótese, o correto será o uso da revisão criminal, porque o juiz das execuções se de um lado não pode se furtar do exame cognitivo das provas produzidas, de outro, não tem o dever de abrir “nova” instrução probatória nessa fase executiva. Sempre que o caso exigir exame valorativo (que não se confunde com o simples exame cognitivo) de provas, ou mesmo produção de provas novas, a via adequada é a da revisão criminal.

Conclusão: preenchidos os requisitos desse novo art. 33, § 3º, ele deve ter incidência retroativa e vai alcançar todos os fatos passados, aplicando-se a pena privativa de liberdade da nova lei, mantendo-se a pena de multa da antiga. Com isso fica patente que o juiz não está “criando” uma terceira lei, ou seja, o juiz não está “inventando” nenhum tipo de sanção: apenas vai aplicar as partes benéficas de cada lei, aprovada pelo legislador. O que está vedado ao juiz é ele “inventar” um novo tipo de sanção. Isso não pode. Aplicar tudo aquilo que foi aprovado pelo legislador o juiz pode (e deve).

Na primeira parte deste artigo citamos seis situações de conflito temporal entre a nova lei de drogas (Lei 11.343/2006) e a antiga. Outros exemplos que podem ser lembrados são as seguintes:

g) Sétimo:

O art. 34 da Lei nova é irretroativo, pois, repetindo os mesmos núcleos do art. 13, previu consequências penais (pena pecuniária) mais gravosas. Atenção apenas para a Súmula 711 do STF, no caso de crime permanente.

h) Oitavo:

O art. 35, *caput*, da Lei nova é irretroativo, pois, repetindo os mesmos núcleos do art. 14, previu consequências penais (corporal e pecuniária) mais gravosas. Deve ser lembrado que a pena para o art. 14 foi alterada pela Lei 8.072/90, passando para a baliza de 3 a 6 anos (a mesma do art. 288 do CP). Atenção apenas para a Súmula 711 do STF. O art. 36, parágrafo único, é lei nova incriminadora, aplicável somente para os casos futuros (irretroativa).

i) Nono:

O comportamento descrito no art. 37, antes da nova Lei, era encarado como partícipe do tráfico, respondendo com a mesma pena do traficante (3 a 15 anos), na medida de sua culpabilidade (art. 29 do CP). Agora, prevendo-se uma exceção pluralista à teoria monista, pune-se o mero colaborador (“papagaio”) com pena mais branda, devendo a norma retroagir, alcançando os fatos pretéritos. Sobre a competência para aplicar a lei nova mais favorável, veja nossos comentários ao art. 33, § 3º, supra.

l) Décimo-primeiro:

O art. 38, repetindo os mesmos núcleos do art. 15, previu nova forma de negligência com consequência penal (pecuniária) mais gravosa. A mudança, portanto, é irretroativa.

m) Décimo-segundo:

Antes da nova Lei o comportamento descrito no art. 39 era mera contravenção penal de direção perigosa (art. 34). Agora, etiquetado como crime, tem pena mais grave, sendo a mudança irretroativa.

n) Décimo-terceiro (causas de aumento de pena, art. 40):

O antigo artigo 18, III, da Lei 6.368/1976, previa como causa de aumento de pena (de um a dois terços) o tráfico decorrente de associação. Também era previsto (no art. 14) o delito de associação para o tráfico. A diferença entre tais dispositivos era a seguinte: no caso de associação permanente (estável) incidia o art. 14. No caso de associação ocasional (temporária) tinha aplicação o art. 18, III (ou seja: art. 12 c.c. art. 18, III).

Essa causa de aumento de pena não foi repetida na Lei 11.343/2006 (o assunto foi disciplinado no art. 40). São muitas as causas de aumento de pena previstas neste último dispositivo legal, entretanto, da associação ocasional ele não cuidou. Conclusão: houve uma espécie de *abolitio criminis*, isto é, desapareceu do ordenamento jurídico essa causa de aumento de pena. Nesse ponto a lei nova é favorável. Quem antes foi condenado e sua pena foi agravada em razão dessa causa, deve agora ser beneficiado com a lei nova. E quem aplica a lei nova mais favorável? Juiz do processo ou tribunal ou juiz das execuções (conforme o caso, como vimos acima nos nossos comentários ao art. 33, § 3º).

o) Décimo-quarto (aumento mínimo do art. 40 mais favorável):

As causas de aumento novas incluídas no art. 40 (e que não constavam do antigo art. 18) só terão incidência de 08.10.06 para frente (ou seja: para crimes ocorridos dessa data para frente). No que diz respeito às causas de aumento de pena que já constavam no antigo art. 18 temos o seguinte: antes o aumento mínimo era de um terço; agora o aumento mínimo é de um sexto.

Nos casos em que o réu já tenha sido condenado e o juiz fixou o aumento mínimo (um terço), impõe-se o ajuste para um sexto. Lei nova mais favorável retroage. Nas situações em andamento (processos em andamento relacionados com crimes ocorridos antes de 08.10.06), o juiz já deve levar em conta que o aumento mínimo é de um sexto (não de um terço).

p) Décimo-quinto (tráfico ocasional: novo art. 33, § 4º):

O § 4º do art. 33 traz uma nova causa de diminuição de pena que não existia antes. Diz o diploma legal: “Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

No chamado tráfico ocasional a lei nova prevê uma causa de diminuição da pena, que tem incidência retroativa. O juiz ou tribunal deve levar em conta a pena antiga (para os crimes antigos, cometidos até 07.10.06). A nova causa de diminuição da pena incide nos crimes antigos, ou seja, na visão do legislador, o injusto penal (tráfico) praticado por traficante ocasional conta com menor reprovação. Essa diferenciação de tratamento deve alcançar os fatos passados. Mudou a perspectiva do legislador assim como a graduação punitiva do fato. Não há dúvida que tudo isso trouxe benefício para o criminoso. E lei nova mais favorável, sempre deve retroagir. Não pode o juiz, em relação aos fatos antigos, levar em conta a pena nova (de 5 a 15 anos). Nesse ponto a lei nova é mais severa (não retroage). Sintetizando: aplica-se a pena antiga com a diminuição nova.

q) Décimo-sexto (benefícios penais cabíveis):

Para crimes ocorridos de 08.10.06 para frente não cabe sursis, graça, anistia, indulto, penas substitutivas etc. (art. 44). Os crimes ocorridos anteriormente (até 07.10.06) contam, entretanto, com tratamento distinto: antes do advento da nova lei, por exemplo, o STF admitia penas substitutivas (penas restritivas) para o caso de tráfico (STF, HC 84.928, rel. Min. Cezar Peluso). Os crimes anteriores devem ser regidos pelo direito anterior, sempre que mais benéfico.